

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

**nr. 248.419 van 1 oktober 2020
in de zaak A. 231.719/XII-8951**

In zake: de NV RAMAST BOUW
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Tim De Ketelaere
kantoor houdend te 3000 Leuven
Bondgenotenlaan 155a
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN (OCMW) VAN BRUSSEL
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Antoine de le Court
kantoor houdend te 1060 Brussel
Jourdanstraat 31
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 9 september 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van BRUSSEL van 15.07.2020 waarbij de raamovereenkomst en de latere opdrachten gegund wordt

- a) voor perceel 1 (onderhouds-, herstellings- en opkuiswerken van daken – m.i.b.v. levering en plaatsing en punctuele depannage- en herstellingswerken) aan de NV SETIP GCUBE;
- b) voor perceel 2 (complete renovatiewerken van daken van diverse bestaande gebouwen) aan de NV BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN.

(besteknummer DE/20/001/I/FPA-FPU/N//1315-CSC 01/20 (ID:1315))”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 september 2020, om 11.00 uur.

Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Tim De Ketelaere, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Natacha Dugardin, die *loco* advocaat Antoine de le Court verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Het OCMW van Brussel schrijft een overheidsopdracht van werken uit met betrekking tot onderhouds- en renovatiewerken van daken in haar openbaar en privé-patrimonium. Het bedrag van de opdracht wordt geraamd op 2.400.000,00 euro, btw niet inbegrepen.

De opdracht wordt gegund met een openbare procedure en betreft een raamovereenkomst. De prijs is het enig gunningscriterium.

De duur van de raamovereenkomst wordt bepaald op 12 maanden, die maximaal driemaal stilzwijgend verlengd kan worden met een periode van 12 maanden.

De raamovereenkomst omvat 2 percelen:

- Perceel 1 heeft betrekking op onderhouds-, herstellings- en opkuiswerken van daken – met inbegrip van levering en plaatsing en punctuele depannage, zowel in het privé als in het openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel;
- Perceel 2 heeft betrekking op complete renovatiewerken van daken van diverse bestaande gebouwen, zowel in het privé als in het openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel.

3.2. Vier ondernemingen dienen een offerte in voor perceel 1, vijf ondernemingen voor perceel 2. De verzoekende partij dient voor de beide percelen een offerte in.

3.3. Op 26 juni 2020 stelt het departement der Werken van het OCMW van Brussel een verslag op.

Voor perceel 1 worden alle inschrijvers geselecteerd en worden alle offertes regelmatig bevonden. Op grond van de prijs wordt voorgesteld om de raamovereenkomst te gunnen aan de als volgt geklasseerde deelnemers: 1. de nv Setip Gcube; 2. de verzoekende partij; 3. de nv Bouwwerken De Raedt Ivan en 4. de bvba Petrus Devos & Zoon.

Voor perceel 2 wordt één inschrijver niet geselecteerd omdat hij niet over de vereiste erkenning beschikt voor dit perceel. De overige offertes worden regelmatig bevonden. Op grond van de prijs wordt voorgesteld om de raamovereenkomst te gunnen aan de als volgt geklasseerde deelnemers: 1. de nv Bouwwerken De Raedt Ivan; 2. de nv Setip Gcube; 3. de bvba Jacobs & fils en 4. de verzoekende partij.

3.4. Op 15 juli 2020 beslist de verwerende partij de opdracht te gunnen overeenkomstig de voorstellen opgenomen in het voormelde verslag.

Dit is de bestreden beslissing.

Hiervan wordt kennis gegeven aan alle inschrijvers bij e-mailbericht en aangetekend schrijven van 25 augustus 2020.

IV. Ontvankelijkheid van de vordering

4. Vooralsnog bestaat er geen noodzaak om over de door de verwerende partij opgeworpen ontvankelijkheidsexcepties uitspraak te doen. Een onderzoek van en een uitspraak over die excepties zou alleen nodig zijn indien de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat, zoals hierna zal blijken, niet het geval is.

V. Schorsingsvoorwaarden

5.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

5.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Overeenkomstig artikel 31 gelden deze bepalingen ook voor opdrachten die de drempelbedragen voor Europese bekendmaking niet bereiken.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

VI. Onderzoek van het enig middel

Uiteenzetting van het middel

6. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 76, § 5, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 2017), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen’, van het bestek nr. 01/20 *juncto* het beginsel *patere legem quam ipse fecisti* en van het algemene motiveringsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.

De verzoekende partij betoogt dat de offertes van de andere inschrijvers nietig moesten worden verklaard wegens substantiële onregelmatigheid, aangezien zij als enige, namelijk op 3 juni 2020, in aanwezigheid van J.D. namens de verwerende partij, ter plaatse een bezoek heeft verricht en de overige inschrijvers nooit ter plaatse zijn geweest.

De verzoekende partij licht toe dat het bestek wel degelijk de verplichting bevat om ter plaatse te gaan. Zij verwijst naar artikel 7.9 van het bestek nr. 01/20 waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een inschrijver bij zijn offerte “verplicht” onder meer een “attest van plaatsbezoek (bijlage J)” moet voegen, naar bladzijde 89 van het bestek waar eveneens uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het “‘attest plaatsbezoek’ BIJLAGE J” verplicht is, naar het typevoorbeeld inzake de offerte, opgenomen vanaf bladzijde 91 van het bestek waar nogmaals wordt bevestigd dat het “attest van plaatsbezoek” een verplicht bij de offerte bij te voegen document betreft.

Zij benadrukt dat uit de uitdrukkelijk vermelding van “verplicht bij de offerte te voegen (document)” alleen al het belang kan worden afgeleid dat de opdrachtgever hecht aan het zich ter plaatse vergewissen van de situatie “teneinde alle elementen te appreciëren om een offerte in te dienen voor deze opdracht”.

Zij wijst erop dat, gelet op de beoogde werken, het verplicht plaatsbezoek de inschrijver de gelegenheid geeft de moeilijkheidsgraad van de opdracht te kunnen inschatten zodat hij een prijs opgeeft die daarmee rekening houdt. Volgens haar maakt een tekortkoming aan deze verplichting dan ook een substantiële onregelmatigheid uit.

De verzoekende partij verwijst hieromtrent nog naar rechtspraak van de Raad van State waarin wordt geoordeeld dat de aanbestedende overheid een plaatsbezoek verplicht mag voorschrijven en vragen daarvan een bewijs te voegen bij de offerte, en dit als garantie dat de inschrijver alle eventuele moeilijkheden en problemen heeft kunnen inschatten zodat hij aldus een offerte met kennis van zaken kan opstellen en zijn prijszetting op geïnformeerde wijze kan bepalen.

Zij benadrukt dat aldus te dezen “een plaatsbezoek de garantie [geeft] dat de inschrijvers zich terdege bewust zijn van de specifieke context van de gebouwen, de uit te voeren dakwerken en dat alle uit te voeren opkuis-, onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken aan de daken van haar diverse gebouwen wel degelijk kunnen worden uitgevoerd”.

De verzoekende partij betwist ten slotte nog de vaststelling in de bestreden beslissing met betrekking tot het perceel 2, dat het deelnemen aan een plaatsbezoek en/of het bijbrengen van een attest van plaatsbezoek niet van toepassing zou zijn. Zij wijst erop dat perceel 2 een grotere waarde vertegenwoordigt, omvangrijker is qua uit te voeren werken – complete renovatiewerken in plaats van louter onderhoud, herstellingen en/of opkuis – talrijke gebouwen en woonentiteiten als voorwerp heeft, en betrekking heeft op een grootstedelijke context zodat een plaatsbezoek *a fortiori* belangrijk is voor dit perceel.

Zij merkt tevens op dat in het bestek nergens wordt aangegeven dat de verplichting tot plaatsbezoek en/of het bijbrengen van een attest van plaatsbezoek niet zou gelden voor perceel 2, zodat de verwerende partij afwijkt van haar eigen bestek.

Beoordeling

7. Het bijzonder bestek dat de opdracht beheerst, legt op dat de inschrijver “verplicht” het attest van plaatsbezoek voegt bij zijn offerte. Een bijlage, gehecht aan het bestek, luidt:

“



**HOOGSTRAAT 298a
1000 BRUSSEL
DEPARTEMENT DER WERKEN**

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 01/20

VOORWERP : Perceel 1 : onderhouds-, herstellings- en opkuiswerken van daken – met inbegrip van levering en plaatsing en punctuele depannage- en herstellingswerken

REFRENTIE VAN HET DOSSIER: DE/20/001/I/FPA-FPU/N//1315 - CSC 01/20

GEBOUWEN :

Linnendienst – Hertstraat 375, 1070 Brussel

Home Juliette Herman – Medoristraat 68-70 , 1020 Brussel

Residentie de Wilde Rozen – Sint-Pieter en Pauwelsstraat 15, 1120 Brussel

Medoristraat 58a –Medoristraat, 1120 Brussel

Medoristraat 58 b, 1020 Brussel

Maloulaan 52 à 60, 1000 Brussel

Samaritaanessestraat 2, 1000 Brussel

Timmerhoutkaal 9, 1000 Brussel

Huis Heizel – Heizelstraat 1, 5 en 7, 1020 Brussel

Overwinningstraat 71, 1060 Brussel

Blaesstraat 113, 1000 Brussel

Plaastingsprocedure : OPENBARE PROCEDURE

ATTEST VAN PLAATSBEZOEK :

Ik ondergetekende
vertegenwoordiger van de Directie der Werken
verklaar op eer dat de onderneming..... de site heeft
bezoekt van het volgende project :
in datum van.....202... teneinde alle elementen te appreciëren om een offerte in te
dienen voor deze opdracht

Handtekening :

Voor de ondernemer,

Voor de Directie der Werken,

”

8. Het verslag van nazicht van de offertes van 26 juni 2020 vermeldt, wat het plaatsbezoek betreft, dat de inschrijvers voor perceel 1 aan dat

vereiste hebben voldaan (“IN ORDE”). Inzake perceel 2 wordt in het verslag hieromtrent bij alle inschrijvers opgenomen: “nvt”.

Alle offertes worden regelmatig bevonden.

9. De verzoekende partij voegt bij haar offerte een ondertekend attest van plaatsbezoek, waarin wordt verklaard dat zij op 3 juni 2020 de plaatsen heeft bezocht. Zij betoogt dat de overige inschrijvers geen plaatsbezoek hebben afgelegd, met de substantiële onregelmatigheid van hun offertes als gevolg.

10. Niet betwist wordt dat een plaatsbezoek verplicht wordt opgelegd door het bestek om regelmatig in te schrijven voor perceel 1.

Uit het administratief dossier blijkt dat de gekozen inschrijver voor perceel 1 een dergelijk attest van plaatsbezoek heeft gevoegd bij zijn offerte.

11. Dat attest voldoet op het eerste gezicht echter niet aan de vereisten bepaald bij bijlage J, omdat het niet is ondertekend door een “vertegenwoordiger van de Directie der Werken”.

12. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de overige inschrijvers bij hun offerte een “attest van plaatsbezoek” hebben bijgevoegd, dat niet door een vertegenwoordiger van de directie der Werken ondertekend is.

13. De verwerende partij voert aan dat wegens de mondiale gezondheidscrisis naar aanleiding van de COVID-19-pandemie zij per e-mailbericht aan de inschrijvers die vragen hadden over het verloop van het plaatsbezoek, had laten weten dat er geen geleid bezoek in de gebouwen zou plaatsgrijpen. Het attest mocht worden ingevuld alsof het een verklaring op eer was.

14. Zij betoogt dat op het ogenblik dat de huidige gunningsprocedure liep en zij diende over te gaan tot de beoordeling van de offertes voor deze opdracht het, gelet op het stijgende aantal besmettingen met het

COVID-19-virus, nodig was om maatregelen te nemen teneinde een nieuwe ziektegolf te vermijden, zoals bepaald in de aanhef van het ministerieel besluit van 5 juni 2020 ‘houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’.

In de gegeven omstandigheden mag op het eerste gezicht worden aangenomen dat de verwerende partij zich in een overmachtsituatie bevond en zij met haar beslissing om de inschrijvers te verzoeken om zelf het attest van plaatsbezoek te ondertekenen, hiermee op eer verklarend dat zij de in de bijlage J opgelijste gebouwen hadden bezocht door de daken ervan te aanschouwen van op de straat, lijkt te hebben gehandeld in functie van de opgelegde noodzaak om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken en dit op een wijze waardoor de mededinging niet in het gedrang lijkt te zijn gebracht.

Daarbij dient ook te worden bedacht dat de betrokken opdracht een raamovereenkomst betreft, waaraan nadien nog invulling dient te worden gegeven door concrete opdrachten, zodat een geleid bezoek aan de binnenzijde van de opgelijste gebouwen in de gegeven omstandigheden niet onontbeerlijk lijkt te zijn om de opdracht te gunnen.

Dat de verzoekende partij blijkbaar een werfcontroleur die geen vertegenwoordiger van de Directie der Werken was, bereid heeft gevonden om haar attest van plaatsbezoek te ondertekenen – en waarbij aldus de rechtsgeldigheid van zijn vaststelling mag worden betwijfeld – houdt in de voornoemde uitzonderlijke crisissituatie op het eerste gezicht niet in dat de verwerende partij tot een wering van de offertes van de overige inschrijvers had moeten besluiten, net zomin als dat het geval is voor de verzoekende partij, doordat het attest niet was ondertekend door een vertegenwoordiger van de verwerende partij.

15. Wat de betwisting over de vraag of het attest van plaatsbezoek ook dwingend was voorgeschreven voor perceel 2 betreft, wordt vastgesteld wat volgt.

Telkens in het bestek wordt verwezen naar het “attest van plaatsbezoek” wordt melding gemaakt van “bijlage J”. In die bijlage wordt het voorwerp ervan omschreven: “Perceel 1: onderhouds-, herstellings- en opkuiswerken van daken – met inbegrip van levering en plaatsing en punctuele depannage- en herstellingswerken”.

Het attest van plaatsbezoek was dienvolgens op het eerste gezicht enkel door het bestek opgelegd voor een inschrijving in perceel 1. Dat bij de inschrijving voor perceel 2 geen attest van plaatsbezoek zou zijn opgenomen in de offerte, lijkt de bestreden beslissing om die reden alleen al niet te kunnen vitiëren.

VII. Besluit

16. Het enig middel is niet ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden verworpen.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt de vordering.

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 200 euro en een bijdrage van 20 euro.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van een oktober tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Johan Bovin,	staatsraad, waarnemend voorzitter,
bijgestaan door	
Greta Scheveneels,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Greta Scheveneels

Johan Bovin